Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacent11vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5104669-88.2022.8.21.0001/RS

AUTOR: GILBERTO ANTONIO SCHUH

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

SENTENÇA

VISTOS.

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por **GILBERTO ANTONIO SCHUH** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA** alegando ter sido diagnosticado com Esclerose Sistêmica, sob o CID 10: M 34, com diversas complicações e patologias associadas, obtendo prescrição para uso do medicamento chamado OFEV (nintedanibe). Aduziu que a cobertura do fármaco foi negado pela requerida, por supostamente não possuir previsão nas diretrizes de utilização da agência reguladora. Contou que o medicamento tem custo de cerca de R$ 21.000,00. Manifestou que precisa de urgência na obtenção do fármaco e possui risco de vida. Discorreu sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Versou sobre a boa-fé objetiva e função social do contrato, assim como sobre a legislação dos planos de saúde e o caráter antineoplásico do fármaco. Pediu liminarmente que a ré seja compelida a fornecer o tratamento prescrito pelo médico, custeando o medicamento OFEV - Nintedanibe, 150mg. Ao final, requereu a confirmação da liminar. Postulou, ainda, pela concessão da AJG. Juntou documentos.

Concedida a liminar para determinar à ré que forneça ao autor o medicamento Nintedanibe - OFEV 150mg, em periodicidade mensal e quantidade suficiente para administração de um comprimido a cada 12h, conforme o receituário médico. Ainda foi indeferida a AJG.

Custas recolhidas nos eventos 16 e 17.

Devidamente citada e intimada, a requerida ofereceu contestação. Sustentou que o medicamento em questão não possui previsão nas Diretrizes estabelecidas pelo Rol de Procedimentos da ANS, em especial nos artigos 17, § único, VI e 18, IX e X, da Resolução Normativa nº465/2021/ANS. Defendeu a taxatividade do rol de procedimentos da agência reguladora, destacando o posicionamento da 2ª Seção do STJ sobre o tema. Afirmou que o medicamento não é destinado para o tratamento de câncer e ainda se caracteriza como medicamento de uso domiciliar, amoldando-se à falta de cobertura disciplinada no artigo 10, inciso VI, da legislação de regência. Postulou pela improcedência da demanda, com as cominações de estilo, e juntou documentos.

Houve réplica.

Instadas sobre o interesse na produção de provas, a ré pediu o julgamento do feito, enquanto o autor noticiou a melhora do quadro de saúde, postulando prazo de 10 dias para juntada de laudo.

Deferido o prazo, o autor se manifestou, acerca do que oportunizado o contraditório.

Juntada documentação, foi concedida vista ao autor, que se manifestou.

Vieram os autos conclusos.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

A solução da demanda independe de outras provas, incidindo, por consequência, o artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Afigura-se, pois, dispensável a dilação probatória, sendo, ademais, medida que atende aos princípios de economia processual e da celeridade da justiça.

Trata-se de ação pela qual a parte autora postula que a ré seja compelida a custear o tratamento prescrito pelo médico, através do uso do medicamento chamado OFEV - Nintedanibe, 150mg.

Nessa linha, inegável a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios que norteiam as relações de consumo, disposições que devem ser aplicadas em conjunto com o regramento especial dos plano de saúde (Lei n° 9.656/98).

A autora é cliente dos serviços prestados pela ré, enquadrando-se no conceito de consumidor, nos moldes do artigo 2.º da Lei nº 8.078/90. A parte ré, por seu turno, na condição de prestadora de serviços, enquadra-se no conceito de fornecedora, nos termos do artigo 3.º, do mesmo diploma legal.

Aliás, tal questão restou sedimentada, a partir da edição da Súmula 608/STJ, que assim dirimiu a controvérsia:

> ***"Súmula 608:*** *Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão."*

Pois bem. No caso em tela, é incontroversa a relação jurídica mantida entre as partes, através do plano de saúde "PFGN1A - UNIMAX FAMILIAR GLOBAL PRIVATIVO". Incontroversa, ainda, a patologia que acomete o autor (Esclerose Sistêmica, sob o CID 10:M 34) e a existência de prescrição médica para o uso do medicamento postulado (Evento 1.5).

Em suas razões de defesa, a demandada aduz a inexistência de cobertura, por se tratar de medicamento de uso oral e que não se enquadra como tratamento antineoplásico.

Vejamos, ainda, a síntese da negativa administrativa:

Justificativa
Vimos pela presente informar que o medicamento **OFEV (NINTEDANIBE)** para uso Domiciliar/Ambulatorial, não está previsto nas Diretrizes estabelecidas no Rol de Procedimentos Art. 17, § 1º, item VI e Art. 18 IX e X, da Resolução Normativa n.º 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Não assiste razão à demandada.

A legislação dos planos de saúde editada no ano de 1998 instituiu o plano de referência assistencial em saúde, pelo qual as operadoras possuem o dever de prestar cobertura aos tratamentos prescritos pelo médico da paciente, com exceção daqueles previstos no artigo 10 da Lei n° 9.656/98, que prevê expressamente as hipóteses que podem ser excluídas da cobertura de plano de saúde médico-hospitalar.

> *"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental;*
>
> *II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim;*
>
> *III - inseminação artificial;*
>
> *IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética;*
>
> *V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados;*
>
> *VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar;*
>
> *VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico;*
>
> *IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes;*
>
> *X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.*

É verdade que dentre as hipóteses de exclusão está o uso de medicamentos para tratamentos domiciliares, tal como o medicamento objeto dos autos, o que conduziria à conclusão de inexistência de cobertura pela parte demandada, confirmando a negativa administrativa. Outrossim, por força do artigo 10, §4º, da Lei n° 9.656/98, compete à ANS regular a amplitude das coberturas disciplinadas, o que o faz por meio da Resolução Normativa n. 465/2021[1], que exclui o medicamento de uso domiciliar das garantias obrigatórias pela operadora (artigo 17, inciso VI).

Nada obstante, é importante observar que o caso dos autos é de situação peculiar.

Isso porque há clara indicação médica no sentido de que o tratamento prescrito ao paciente, através da utilização do OFEV - Nintedanibe (150mg) constitui escolha residual, por exclusão.

Veja-se que o médico do paciente esclarece que há risco de vida ao paciente, devido à piora pós quadro de Covid-19, complementando que "*Não há outra medicação disponível no SUS para tratamento da doença*". Ademais, há expressa ressalva no sentido de que o demandante já utilizou outros medicamentos associados à doença, tais como *azatioprina* e *micofenolato de mofetil* (Evento 1.5).

Não se olvide, ainda, que o demandante possui histórico de câncer intestinal, circunstância que, conforme laudo médico, limita ainda mais as hipóteses terapêuticas, excluindo, por exemplo, a utilização de fármaco análogo, chamado de *ciclofosfamida* (Evento 1.5).

PACIENTE

Gilberto Antonio Schuh

CPF: 268.501.090-49

Iniciou com dispnéia e tosse em 2020 .Apresentou mãos de mecânico , Fenômeno de Raynaud , esclerodermia , e Eritema periorbitário na evolução do quadro. Emagreceu 9 quilos com a doença . TC de tórax com PINE fibrosante progressiva. HD : familiares com polimiosite. Exames no diagnóstico: VSH 48, Ferritina 630, FAN 1/640 citoplasmatico pontilhado fino denso. Vinha bem clinicamente , entretanto, após quadro de covid houve piora dos sintomas , tosse intensa , dispnéia e a tomografia mostrou progressão do quadro . Já em uso de micofenolato 500 mg 4 cp ao dia . CVF 50 %.(04/2022).

Solicito ofev -nintedanibe 150 mg 12 em 12 horas .solicito medicação com urgência e há risco de vida , devido a ativação da doença em paciente com capacidade vital forçada reduzida em 50 %.Apresenta um quadro dermatomiosite sobreposto a quadro de esclerose sistêmica.Não há outra medicação disponível no SUS para tratamento da doença . Já usou azatioprina e micofenolato de mofetil .História de neoplasia intestinal contraindica uso de ciclofosfamida.

CID M34 -ES-DPI

13 de Abril de 2022

Sublinhe-se, por oportuno, que o autor ainda logrou acostar outros dois laudos médicos no sentido de que houve substancial evolução do quadro de saúde após a ministração do medicamento, demonstrando a existência de evidências científicas favoráveis e específicas ao caso dos autos (Eventos 33.2 e 36.2).

Nesse cenário, tem-se por preenchidos os pressupostos legais disciplinados pelo novel §13º, inciso I, do artigo 10, da Lei n. 9.656, que autoriza extrapolar as diretrizes de procedimentos estabelecidos pela agência reguladora, quando **baseado em evidências científicas e plano terapêutico**.

> *"Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:*
>
> *(...)*
>
> ***§ 4º A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes e de procedimentos de alta complexidade, será estabelecida em norma editada pela ANS, que publicará rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado a cada incorporação.***
>
> *(...)*
>
> *§ 12. O **rol** de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela **ANS** a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.*
>
> ***§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:***
>
> ***I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou***
>
> *II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." (NR)* ***(grifei)***

Em caso análogo, esse também foi o posicionamento da jurisprudência do E. TJRS:

> *AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE FIBROSE PULMONAR PROGRESSIVA. MEDICAMENTO NINTEDANIBE (OFEV). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE DA ANS TAXATIVO. DUT RELATIVIZADA SOB FUNDAMENTO RELEVANTE. 1) Embora atualmente não haja uma pacificação na jurisprudência, vez que a Terceira Turma da Corte Superior adota posição de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, neste momento, após estudos da legislação e casos, está Câmara concluiu por rever posicionamento e alinhar os julgados ao entendimento sufragado no REsp 1.733.013/PR, no sentido de que o rol é taxativo, sobretudo considerando que o referido rol da autarquia regulamentadora não visa privilegiar nenhuma das partes, mas apenas harmonizar a relação contratual com substrato em diretrizes técnicas relevantes. 2) Não obstante, no julgamento do REsp 1.733.013, balizador do novel entendimento, restou expressamente consignado que, sob pena de violação do próprio princípio do acesso à justiça e diante do risco do estabelecimento ilegal de presunção absoluta (juris et de jure) de higidez dos atos da Administração Pública, com a adotação do entendimento do Rol Taxativo da ANS não se está a dizer que não possam existir situações pontuais em que o julgador, amparado de informações técnicas relevantes, submetidas ao contraditório, em decisão racionalmente fundamentada, venha determinar o fornecimento de certa cobertura que constate ser efetivamente imprescindível, com supedâneo em medicina baseada em evidência (clínica). 3) Caso dos autos em que, a despeito de a cobertura do medicamento Nintendanibe (OFEV), nas Diretrizes estabelecidas no Rol de Procedimentos da RN 465/2021, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ser apenas devida quando houver diagnóstico de câncer pulmonar, restou devidamente demonstrado que o tratamento prescrito pelo médico pneumologista do autor, com medicamento ambulatorial anti-fibrótico, o qual é preconizado pelas diretrizes nacionais e internacionais para fibrose pulmonar, com o objetivo de evitar progressão da doença e seus sintomas de falta de ar, tosse e insuficiência respiratória, mediante o medicamento Nintedanibe, é o único aprovado no Brasil pelas agências reguladoras. 4) Configurado caso de exceção à regra descrita no julgado REsp 1.733.013, vez que o quadro clínico do autor se traduz em situação pontual, que diante das informações técnicas relevantes contidas nos autos, impõe o fornecimento da cobertura do fármaco postulado, por ser imprescindível o tratamento em questão e estar baseada em evidência (clínica). 5) Outrossim, o egrégio STJ possui orientação no sentido de que a cobertura contratual não pode excluir a dispensação de medicamento de natureza experimental ou off label (sem previsão de utilização específica em bula do medicamento), a despeito do disposto no art. 20, § 1º, inciso I, alínea c, da Resolução Normativa nº 428/2017 da ANS, por lhe estar vedada a limitação de tratamentos a que o paciente pode se submeter. POR MAIORIA, DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 50589261020228217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 30-06-2022)*

Sendo assim, inafastável a conclusão pelo dever de cobertura do plano de saúde, ora requerido.

Nessa conjuntura, a confirmação da liminar e procedência da demanda é medida que se impõe.

DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo ***PROCEDENTES*** os pedidos formulados por **GILBERTO ANTONIO SCHUH** em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA** para ***CONFIRMAR*** a tutela provisória de urgência e ***DETERMINAR*** que a ré forneça ao autor o medicamento Nintedanibe - OFEV 150mg, em periodicidade mensal e quantidade suficiente para administração de um comprimido a cada 12h, conforme o receituário médico do Evento 1 - RECEIT6.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador do autor, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, atualizado pelo IGP-M desde o ajuizamento, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC, considerando a natureza da causa e o trabalho desenvolvido.

Havendo interposição de apelação no prazo recursal, intime-se o apelado, para, querendo, oferecer contrarrazões. Após, nada mais ensejando intervenção do juízo de primeiro grau, remeta-se ao TJRS. Do mesmo modo, na hipótese de interposição de apelação adesiva, vista à parte contrária para apresentação de contrarrazões, no prazo legal, sendo, após, remetido ao TJRS.

Não havendo interposição de recurso certifique-se o trânsito em julgado e, uma vez recolhidas eventuais custas, arquive-se com baixa.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Documento assinado eletronicamente por **CINTIA DOSSIN BIGOLIN, Juíza de Direito**, em 1/2/2023, às 14:58:3, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10031714673v19** e o código CRC **8c827759**.

---

1. <https://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=NDAzMw==> ↩